

1500458-47.2021.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Eldorado

Foro: Foro de Eldorado Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... de designios para o fim de cometer delito de associação para o tráfico.

Assim, a autoria do delito de associação para o tráfico não está comprovada.

c) Aplicação do privilégio

Importante ainda ressaltar que, restando caracterizado a associação para o tráfico não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da lei de Drogas) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Eldorado

Foro de Eldorado Paulista

Vara Única

Rua Professor Francisco Canto, 14, Eldorado-SP - cep 11960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500458-47.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500458-47.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347792/2021 - DEL.POL.IPORANGA, 22085713 - DEL.POL.IPORANGA, 234/21/405 - DEL.POL.IPORANGA, 2347792 -

DEL.POL.IPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DENI KENIDE CAVALCANTI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

## I - RELATÓRIO

DENI KENIDE CAVALCANTI e DINIZ CAVALCANTI foram processados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, porque: 1º FATO: Em momento desconhecido, porém até o dia 22 de dezembro de 2021, em local ignorado, DENI KENIDE CAVALCANTI e DINIZ CAVALCANTI, associaram-se para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 2º FATO: No dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 07h, na residência localizada na Rua Antônio Arcanjo da Rosa, n.º 204, Bairro Caixinha, na cidade de Iporanga/SP, nesta Comarca de Eldorado/SP, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 161 pinos plásticos, todos contendo "crack", com 139 gramas de massa no total, e 15 porções de cocaína, com 10 gramas de massa no total, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia às fls. 247/249:

Segundo apurado, os irmãos DENI KENIDE e DINIZ se associaram para a exploração do tráfico de drogas, tendo se reunido para a realização conjunta da mercancia espúria, repartindo entre si as atribuições inerentes à individualização das substâncias em porções individuais, guarda e venda direta aos usuários, de maneira habitual e quase profissional.

Essa forma de organização, peculiar para a pequena cidade de Iporanga e o relativo sucesso que acumularam no tráfico de drogas - vide o produto da apreensão - bem evidenciam que não o faziam apenas de forma ocasional.

Pois bem, nas condições de tempo e lugar descritas no segundo parágrafo, DENI KENIDE e DINIZ guardavam e mantinham em depósito, na parte de trás do imóvel, no jardim, escondido debaixo de uma telha, uma sacola plástica contendo 90 porções de crack e 06 de cocaína, além de 276 embalagens vazias para acondicionar drogas. Os denunciados também guardavam e mantinham em depósito, dentro do bolso de uma jaqueta, que estava pendurada atrás da porta do quarto do imóvel, uma sacola plástica contendo 71 pinos contendo "crack" e 09 pinos contendo cocaína.

A Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Jacupiranga obteve informações envolvendo a exploração do tráfico de drogas pelos denunciados, e as diligências realizadas pelos policiais confirmaram aquelas suspeitas.

Destarte, foi expedido mandado de busca e apreensão e, durante seu cumprimento foram localizados os entorpecentes, as embalagens vazias, além de apreendida a quantia de R\$ 1.501,00 em espécie, bem como o veículo utilizado no tráfico de drogas. Os denunciados, pois, foram presos em flagrante delito.

Assim, a quantidade e variedade de drogas encontradas em seu poder, a forma de acondicionamento, o modo de embalagem e armazenamento, o comportamento do denunciado, o local em que realizada a prisão, a vultuosa quantia de dinheiro apreendida, além das demais circunstâncias, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, por meio de tráfico ilícito.

Consta dos autos Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), boletim de Ocorrência, Termo de Depoimentos (fls. 07/09) Termo de Interrogatório (fls. 10/13), Nota de Culpa (fls. 14/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/18), Auto de Constatação Preliminar (fls. 19/20), Requisição de Substância Entorpecente (fl. 21/22 e 175/176), Fotos (fls. 26, 212/230, 391/396 e 504), Relatório Final (fls. 177/179), Relatório (fl. 180), Declarações (fls. 231/236 e 237/238), Laudo Pericial (fls. 256/260).

Recebida a denúncia em 19 de janeiro de 2022 (fl. 263/267).

Citados, os acusados ofereceram resposta à acusação (fls. 273/284).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 324/326.

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 31 de março de 2022 foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se com o interrogatório dos réus.

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais às fls. 460/471, pleiteou o julgamento de procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno em alegações finais por memoriais, pleiteia a improcedência da ação e alega insuficiência de provas capazes de corroborarem um decreto condenatório (fls. 475/503).

## II – FUNDAMENTAÇÃO

### a) Tráfico de Drogas

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo diretamente ao exame do mérito.

A materialidade do tráfico de drogas está bem comprovada nos autos por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimentos (fls. 07/09) Termo de Interrogatório (fls. 10/13), Nota de Culpa (fls. 14/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/18), Auto de Constatação Preliminar (fls. 19/20), Requisição de Substância Entorpecente (fl. 21/22 e 175/176), Fotos (fl. 26), Relatório Final (fls. 177/179), Relatório (fl. 180), Laudo Pericial (fls. 256/260), e, sobretudo pela prova oral, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A autoria, por igual, é inconteste, e não resta dúvida de que deve ser atribuída aos réus.

Interrogado, o réu Deni Kenide Cavalcanti negou a prática delitiva, afirmou: "Por volta das 6:30, os policiais compareceram em minha residência, procederam com as buscas, contudo, no interior da casa não foram encontradas drogas. Não avistei as drogas apreendidas na parte externa da casa e não eram de minha propriedade. A quantia em dinheiro de cento e setenta reais era destinada para pagar contas. Posteriormente, levaram-me para casa de Diniz, fiquei dentro da viatura [...] Minha residência não possui jardim, é cheio de mato. Para chegar ao local, é preciso subir uma pequena escada e passar pelo portão, pois o acesso só é feito pela parte da frente."

Interrogado, o réu Diniz Cavalcanti, negou os fatos descritos na denúncia, disse: "Na data dos fatos, por volta de 7h, os policiais compareceram à minha residência. Revistaram os quartos e, em um primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado. O policial civil Anildo retornou ao quarto, e saiu do local com uma sacola que conteria drogas. O policial mencionou que as entorpecentes estariam nas coisas da minha mulher. Os policiais apresentaram uma sacola plástica dizendo que era uma porção de drogas encontrada no quintal da residência de Deni, entretanto, só era possível visualizar a sacola. Tentei explicar que as drogas não eram minhas, porém se aproximou e colocou a arma na minha cabeça [...] Tive dinheiro apreendido, aproximadamente mil e quatrocentos reais, eram notas grandes e variadas. O celular foi apreendido. Nunca tive veículo Corsa. Tenho um Palio, que era utilizado somente para ir ao meu sítio. Não tinha problema com policiais e nem tenho inimigos." Ocorre que a versão oferecida pelos réus destoa do material probatório dos autos. Isto porque, durante a instrução processual, a prova oral, consistente nas declarações das testemunhas, consubstancia sólido elemento de convencimento a demonstrar que as condutas imputadas ao acusado existiram e foram verídicas. Antes de delinear os elementos de cada tipo penal, cabe citar o depoimento das testemunhas.

A testemunha Valdinei Fernandes de Ramos disse: "Recebíamos várias denúncias sobre tráfico de drogas nos endereços dos réus. Na data dos fatos, fomos solicitados pela polícia civil para prestar apoio na busca e apreensão dos acusados. No domicílio de DENI não encontramos nada de ilícito dentro da casa, entretanto, na parte externa tinha uma quantidade de drogas debaixo de uma telha que foi localizado pela polícia civil. Eu não vi as entorpecentes, apenas soube que foram apreendidas. Aos questionamentos do Ministério Público, respondeu: Fomos à casa de Diniz. Havia dois quartos paralelos, no quarto que entrei não foi localizado nada. Já no quarto em que o Anildo ingressou, foi encontrada uma quantidade de drogas. Foram apreendidas as drogas, uma quantidade de dinheiro em espécie e um veículo Palio [...] Conhecíamos os réus dois meios policiais. Tínhamos informações que os dois estavam praticando tráficos, pois populares reclamavam. Aos questionamentos da Defesa afirmou: Exerço a função de policial militar há 24 anos. Em 2021 participei apenas dessa apreensão relacionada ao tráfico. Na data dos fatos, participaram da operação quatro policiais militares. Na casa Kenedi é de fácil acesso para chegar lá. Não me

recordo se tem uma porteira [...] Participei do lado de fora, não vi a droga visualmente. Fiquei na porta principal da casa, mas fiquei mais para o lado de fora [...] Ouvi voz feminina na casa, mas não verifiquei quem era [...] Foi encontrada a droga na parte de trás da casa. Entrei na casa de Diniz junto com Anildo, fiz a vistoria em um dos quartos. Soube que foram encontradas as entorpecentes atrás da porta no bolso de uma jaqueta."

A testemunha Edmar Adilson Viana, Policial Militar disse: "Na data dos fatos, policiais militares e civis foram cumprir um mandado de busca e apreensão, tendo em vista as diversas denúncias sobre o tráfico de drogas. Após diligências, dirigimos na casa de Quendinho, achamos uma quantidade de entorpecentes debaixo da telha uma e um valor em espécie. Posteriormente, seguimos no outro endereço, na casa de Diniz, encontrava-se no local uma equipe de policiais militares e civis. Chegamos para prestar apoio, enquanto Anildo e cabo Valdinei estavam revistando a casa. Anildo encontrou variedade de porções de entorpecentes. Aos questionamentos do Ministério Público respondeu: Os acusados já foram presos pela prática do mesmo crime. Quando o irmão do Quendinho veio a residir na cidade, notou-se a prática de tráfico de drogas por parte dos réus. Depois de realizada campanhas e diversas investigações, concluiu-se que estava sendo realizada a prática delituosa [...] Na data dos fatos, em específico na primeira casa, encontrei a drogas debaixo da telha dinheiro em espécie e inclusive notas de pequeno valor [...] Em conversa com os colegas policiais, ficamos sabendo na residência do outro acusado foram encontradas drogas em um quarto e uma quantidade de dinheiro em espécie. Às perguntas da d. Defesa, respondeu: Exerço a função de policial militar há 25 anos. No dia 22 de dezembro, em razão de várias denúncias anônimas, diante de campanha e diligências, chegamos a conclusão que Kenedi e Diniz estavam praticando a traficância. Na data dos fatos, cada equipe foi para cada casa. Fui à casa de Quendinho, na companhia do delegado e policiais militares. No local fomos atendidos pelo Kenedi, havia uma senhora que seria a genitora do acusado. Encontramos dinheiro em espécie, e no quintal embaixo da telha encontramos a droga. O delegado acompanhou a apreensão. Atuei como escrivão ad hoc. e como testemunha [...] Nas campanhas, constatou-se movimentação de adolescentes e jovens na casa de Deni, durante o período noturno, buscando entorpecentes. Recebíamos denúncias sobre o carro ser utilizado para transporte de drogas e que Quendinho ficava na entrada da cidade para observar a movimentação dos policiais [...] Foi apreendido drogas acondicionadas em tubos do tipo Eppendorf e embalagens para armazenar drogas."

A testemunha Bruno Roberto da Silva, Delegado de Polícia, disse: "As diligências foram desdobramento de investigação realizada pelo policial civil Edmar, havia denúncias que os irmãos estavam realizando tráfico de drogas, ambos já tinham passagens policiais. Na data dos fatos, realizamos uma operação com apoio da polícia militar [...] Foram feitas buscas na residência de Deni e foi localizada, debaixo de uma telha Eternit, na área externa da casa, uma sacola com entorpecentes e plásticos para embalar as drogas [...] Na residência de Diniz, os policiais os policiais civis encontraram drogas no quarto do casal, numa jaqueta que estava pendurada atrás da porta. As buscas se iniciaram apenas após minha chegada ao local [...] Edmar foi nomeado como escrivão, porém elaborei o inquérito. Não me recordo se foi apreendido o celular. A importância em dinheiro foi apreendida por estar associada com tráfico de droga, assim como o veículo apreendido."

A testemunha Renato Machado da Silva, Policial Militar: "A equipe foi dividida em grupos, sendo que uma se dirigiu à casa de Deni e outra para casa de Diniz. Participei da busca na residência de Diniz, no local, o policial Anildo encontrou as drogas, porém não me recordo onde estavam. Foi apreendido o veículo Palio. As drogas estavam acondicionadas em tubos do tipo Eppendorf. Conheci Diniz em razão de passagem por tráfico de drogas."

A testemunha Anildo Gonçalves dos Reis disse: "Participei das buscas e apreensão, fomos designados para ir à casa de Diniz, fomos atendidos pelo réu, a esposa dele estava na residência. O Acusado franqueou a entrada. Após a chegada do delegado, encontrei no bolso de uma jaqueta feminina uma porção de drogas dentro acondicionada em uma sacola plástica. Encontramos dinheiro em espécie. O vestuário não foi apreendido [...] Antes dos fatos, ocorreram investigações para constatar a

prática de tráfico de drogas na casa de Deni."

A testemunha protegida 1 disse: "Na data dos fatos, por volta de 7h, os policiais compareceram à minha residência e indagaram se havia drogas no local. Apresentaram o mandado de busca, revistaram os cômodos da casa e não encontrada nada de ilícito. Posteriormente, chegaram ao local o delegado e Edmar, o primeiro questionou se foi encontrada alguma coisa, por consequência, responderam que não. Ocorre que Edmar ingressou no quarto e, logo em seguida, o delegado cochichou algo para o policial Anildo. Por sua vez, o Anildo voltou ao quarto e saiu com um pacote em mãos. Assim, afirmaram que foram encontradas as entorpecentes dentro dos meus pertences. O delegado deu voz de prisão, Edmar veio e apontou a arma na cabeça de Diniz. [...] Temos uma propriedade rural em Iporanga há nove anos, realizamos o plantio do palmito pupunha. Utilizamos o veículo Palio para se locomover até a propriedade [...] Não apresentaram as drogas apreendidas, apenas mencionaram que foram encontradas. O dinheiro apreendido era proveniente da venda de palmito. O celular e veículo forma apreendidos."

A testemunha protegida 02 aduziu: "Resido em Iporanga há 22 anos. Conheço os réus. Não é do meu conhecimento fatos que desabone ambos. Quendinho auferir renda de trabalhos esporádicos e catando latinhas. Ele vive com uma senhora que é acamada. Não soube que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas. [...] Conheço Diniz há sete anos, dedica-se na plantação de palmito pupunha. O réu possui um veículo Fiat Palio. Não sei se ele teve um veículo Corsa. Fiquei sabendo da prisão dos acusados. Não é do meu conhecimento que o réu se envolveu como tráfico de drogas. Conheço a casa do Quendinho, o local é tranquilo, tem um portão de madeira vazado e não tem muro. Não é do meu conhecimento sobre movimentações suspeitas na casa do acusado. Diniz morava fora de Iporanga, e que esporadicamente vinha à cidade. A residência fica localizada a aproximadamente 12km da cidade. Soube que Deni já esteve preso anteriormente."

Em relação aos depoimentos e a tese de defesa, verifica-se que a versão dos acusados de que as drogas não lhes pertencia, em todos os momentos não se comprova (art. 33 da Lei de Drogas).

No tocante às entorpecentes encontradas na residência de Deni Kenide Cavalcanti, o policial Valdinei, em juízo, destacou que as drogas foram encontradas no lado externo da residência do réu. Essa afirmação foi corroborada pelos depoimentos do policial Edmar e do Delegado de polícia e com as demais provas dos autos que confirmaram que o réu tinha em depósito as drogas.

Referente ao acusado Diniz Cavalcanti, a testemunha Anildo Gonçalves dos Reis disse, em juízo, que localizou as entorpecentes na residência réu dentro do bolso de uma jaqueta, que estava pendurada atrás da porta do quarto.

Evidentemente, os policiais se dividiram em dois grupos, sendo que um foi à casa de Deni e outro se dirigiu à residência de Diniz.

As abordagens ocorreram de forma estratégica para evitar possíveis fugas. Nota-se que o Delegado de Polícia acompanhou toda a operação e esteve presente em ambos os locais. Afirmou em seu depoimento que ordenou que as apreensões ocorressem apenas na sua presença. Por isso a primeira apreensão ocorreu na casa do acusado Deni e em seguida à casa na residência de Diniz.

Desta feita, não é de estranheza que o acusado Diniz e a testemunha protegida 1 tenham mencionado que, em um primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado, haja vista que as buscas sequer tinham iniciado, ocorrendo apenas a abordagem, aguardando-se a chegada do Delegado de Polícia para iniciarem as diligências.

Destaca-se que o depoimento das autoridades públicas tem presunção de veracidade. E, neste caso, não há qualquer elemento que possa enfraquecer a versão de que as drogas foram apreendidas nas duas residências.

Do contrário, seria pressupor que o material foi implantado no local ou que as informações prestadas em Juízo são falsas, o que seria não condizente com as versões apresentadas.

Isso porque, evidentemente, os acusados negam a acusação e afirmam que não estariam praticando delito. No entanto, também afirmaram em seus interrogatórios que nada tinham contra os policiais, inexistindo desavenças pessoais que pudessem motivar a operação.

Evidenciou-se que a residência de Deni era utilizada como ponto de venda de drogas pelo acusado e que Diniz também estava envolvido com a traficância. Anota-se que Deni Kenide Cavalcanti e Diniz Cavalcanti ostentam condenações pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o que demonstra suas condutas reiteradas em delito semelhante. A testemunha Edmar, inclusive, discorreu assim: "[...] Nas campanhas, constatou-se movimentação de adolescentes e jovens na casa de Deni, durante o período noturno, buscando entorpecentes." Logo, do conjunto probatório coligido aos autos não pairam dúvidas de que, de fato, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam e eram destinadas à traficância.

Importante ressaltar que as afirmações da defesa de que a cidade de Iporanga é pequena e que a conduta é incomum, bem como que os policiais atuaram de forma equivocada é de ser afastada, segundo as considerações que a seguir se expõe. Com relação às teses defensivas, a defesa sustentou que a fase inquisitorial do procedimento penal apresenta eventuais vícios, tais como o Auto de Constatação Preliminar ser realizado sem o rigor técnico e que o policial Edmar A. Viana figurou como condutor, primeira testemunha e escrivão de polícia. Ocorre que está acostado aos autos o Laudo Pericial às fls. 256/260, que foi devidamente elaborado pelo Perito Criminal e descreveu detalhadamente as substâncias apreendidas.

No mais, com relação à atuação do policial Edmar, verifica-se que a testemunha atuou nas apreensões na casa do primeiro réu e, posteriormente, prestou apoio nas diligências realizadas na segunda residência, presenciando todos os fatos, assim como a testemunha Bruno. Quanto à atuação como escrivão de polícia, segundo o delegado de polícia, existe a falta de funcionário na região e Edmar possuía habilidades em gerenciar o sistema para elaboração do procedimento.

Ou seja, a deficiência estrutural que leva o procedimento a ser gerido por duas ou três pessoas não é causa de nulidade. Se assim fosse, os inquéritos em regiões em que a polícia enfrenta dificuldades estruturais sequer poderiam ser realizados. Ademais, a alegação sequer condiz com a realidade local, nitidamente extraída de conclusão hipotética sobre a forma de colheita de fatos delituosos. Importa, neste caso, que os documentos apresentem coerência e que a equipe tenha empregado atos lícitos. Eis que o Delegado categoricamente afirmou que o sistema que gera as apreensões somente pode ser acessado por funcionários cadastrados e que a atuação como escrivão de funcionários com outra designação técnica é permitida pelas normas internas da Corregedoria da Polícia.

De igual maneira, a Defesa alegou que o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/18) apresenta omissões, que o policial Edmar e Valdinei apresentaram depoimentos idênticos e que os policiais não filmaram ou fotografaram o local da apreensão das entorpecentes.

Nota-se que o Auto de Exibição e Apreensão elencou os objetos apreendidos de forma geral, contudo, o Boletim de Ocorrência às fls. 03/06 descreve precisamente onde cada item se encontrava, assim como foi mencionado pelas testemunhas de acusação em juízo.

De acordo com as testemunhas, os policiais Edmar e Valdinei participaram da primeira apreensão na casa do réu Deni, e, posteriormente, foram à residência de Diniz para prestar apoio nas diligências. Portanto, os agentes policiais presenciaram os mesmos fatos, não sendo estranho apresentarem depoimentos parecidos. Por isso, na elaboração das peças inquisitoriais, optou-se por um modelo de depoimento único que englobasse todo o testemunho dos agentes, traduzindo de maneira clara e coesa os eventos fáticos.

Na data dos fatos, a operação policial se desenvolveu de forma tática e dinâmica, decidindo-se o que seria pertinente ou não durante a abordagem e apreensão. Desta feita, a ausência de filmagem não desmerece todo o empenho da inteligência policial, tendo em vista que as demais provas dos autos, em especial, a colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, a Defesa aduziu que a apreensão do veículo e aparelho celular de propriedade de Diniz foi ilegal e que não existe justificativa para o confisco da importância em dinheiro dos réus.

Entretanto, considerando o conjunto probatório e as diligências policiais realizadas, conclui-se que o veículo, aparelho celular e as importâncias em dinheiro estavam relacionados à prática delitiva. Assim discorreu a testemunha Bruno Roberto da Silva: "[...] A importância em dinheiro foi apreendida por estar associada com tráfico de droga, assim como o veículo apreendido." Ou seja, tais apreensões tinham como fundamento o fato de o uso do veículo estar relacionado em operação delituosa e a origem do dinheiro, provavelmente, apontar o mesmo. Isso porque, segundo a cognição que se faz no inquérito, a apreensão se realizada pela conduta mais provável, inexistindo qualquer ilegalidade. Pelo contrário, o próprio CPP impõe que sejam apreendidos objetos que importem para o entendimento do delito.

E, depois, se verificado que estão dissociados, devem os acusados ou terceiros fazerem prova por meio de incidente próprio.

Por fim, cumpre registrar que, ainda que existissem vícios na fase inquisitorial, eventuais vícios não prejudicam a ação penal, tendo em vista que os atos são renovados e praticados perante o contraditório e ampla defesa. Nesse sentido inclina-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I – Não demonstrada minimamente a imprescindibilidade da medida, os indícios de autoria e as provas da materialidade na primeira decisão de quebra de sigilo bancário, proferida em sede de inquérito policial, deve ser anulada e as provas decorrentes afastadas dos autos principais. II – Presentes demais provas aptas ao oferecimento e recebimento da denúncia, eventuais nulidades decorrentes do inquérito policial não maculam a ação penal. III – Assente nesta eg. Corte que, verbis: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 6/12/2017). IV – Quanto à segunda decisão judicial objurgada e aqui considerada válida, além da imprescindibilidade da medida, que se extrai do modus operandi integralmente narrado, ou seja, o suposto uso de sites fraudulentos que sempre redirecionavam os valores arrecadados para as mesmas contas bancárias, todas em nome exclusivo do recorrente, os indícios de autoria e as provas da materialidade também foram demonstrados à exaustão. Agravo conhecido e provido em parte para anular a primeira decisão de quebra de sigilo bancário, de 06/05/2016, afastando as provas dela decorrentes. (AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

Por isso, a condenação em relação ao delito de tráfico é medida que se impõe, restando claro o dolo de armar e comercializar o entorpecente, em desacordo com autorização legal, bem como que não existiu no caso qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade que possa militar em seu favor.

#### b) Associação para o tráfico

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), entendo, prescreve o art. 35 da Lei de Drogas:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência para a comercialização de

drogas, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.

Nessa toada, o delito de associação para o tráfico de drogas exige a estabilidade da associação criminosa entre dois ou mais agentes, mediante a divisão de atribuições com a finalidade de praticarem o comércio ilegal de substâncias entorpecentes de forma estável e permanente.

No caso dos autos, após a colheita de todo o arcabouço probatório, entendo que não ficou evidente que os réus estavam reunidos com a intenção de estabilidade e permanência criminosa.

A divisão de tarefas entre eles não estava distribuída, sendo que, pela audiência, o único ponto comum afirmado pelos policiais era o de que, supostamente, eles estariam comentando condutas criminosas.

Informaram que o souberam por meio de denúncias anônimas, mas nada há que tenha delineado o tempo da reunião, a finalidade, os meios executados.

Isso porque, apesar de os Policiais terem noticiado que realizaram campanha, o que foi suficiente para apurarem suposta conduta delituosa, nada narraram em seus depoimentos sobre como eles agiam. Ou seja, o depoimento limitou-se a descrever a operação policial e a apreensão da droga e suposta frequência de moradores na casa de ambos.

O Ministério Público, como detentor da prova, segundo o sistema acusatório, também se limitou a perguntar a respeito da operação, sem colher elementos sobre a suposta associação para o tráfico.

Muito embora a associação possa ser realizada por, no mínimo, duas pessoas, é necessário o convencimento do Juízo de que havia estabilidade e permanência, segundo provas extraídas da fase processual e não apenas do inquérito.

É preciso, ainda, que os depoimentos testemunhais sejam claros e que não se conclua meramente por probabilidade, mas por um juízo límpido do fato que se está a averiguar.

A simples existência de condenação pretérita por delito de igual natureza não pode ser usada como elemento exclusivo de prova, sob pena de bis in idem. Os acusados ostentam condenações pelo cometimento do crime de associação para o tráfico, inclusive no mesmo processo (0002282-96.2015.8.26.0030 - fls. 440 e 444).

Um dos policiais, por sua vez, disse que aquele local já era conhecido como ponto de drogas comandado pelos réus antes da sua prisão. Todavia, nada ficou apurado sobre como supostamente agiam, além do fato de que, eventualmente, estavam praticando tráfico em concurso de pessoas.

Por fim, o simples fato de serem irmãos, o que importa em proximidade afetiva, não implica em unicidade de desígnios para o fim de cometer delito de associação para o tráfico.

Assim, a autoria do delito de associação para o tráfico não está comprovada.

### c) Aplicação do privilégio

Importante ainda ressaltar que, restando caracterizado a associação para o tráfico não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da lei de Drogas) nos termos da jurisprudência do Colendo STJ (HC 438.025/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). Ora, muito embora não tenham sido condenados nestes autos por associação, fato é que já cumpriram pena por delito semelhante em data pretérita. Além disso, fato é que o acusado ostenta inúmeras condenações anteriores, não se tratando de réus primários.

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação dos réus na conduta de tráfico de drogas, sem a forma privilegiada.

## III - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA



Passo à individualização das penas em consonância com o artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria das penas devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequência, e o comportamento da vítima.

1 fase: Os sentenciados apresentam uma circunstância negativa consistente naquela prevista no art. 42 da Lei de Drogas, relativamente à natureza e quantidade. Por terem sido recolhidas mais de uma substância entorpecente, reputo essa circunstância como negativa. Considerando a diversidade das substâncias, importa em acréscimo de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena em abstrato. Assim sendo, quanto ao crime de tráfico de drogas FIXO a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2 fase: Na segunda fase da dosimetria das penas os sentenciados incidem na agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, podendo ser considerados reincidentes, conforme autos nº 0002282-96.2015.8.26.0030, que transitou em julgamento antes da prática dos fatos ora apurados, conforme certidões de fls. 440, 443 e 444. Agravante judicial importa em acréscimo de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência específica, calculado sobre a pena fixada na primeira fase. Quanto ao crime de tráfico de drogas FIXO a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

3 fase: Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, tal qual acima alinhavado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, sobretudo porque amplamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais e reincidentes.

Ausentes informações sobre a situação econômica dos acusados, o valor do dia-multa deve corresponder ao mínimo legal.

#### IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR DENI KENIDE CAVALCANTI e DINIZ CAVALCANTI, qualificados nos autos, pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Inviável o deferimento dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, eis que os acusados não preenchem os requisitos legais, sobretudo em vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena.

INDEFIRO o direito dos réus apresentarem recurso em liberdade, mantendo a prisão decretada nestes autos, pelos fundamentos já expostos e objeto de reavaliação noventenária, nos termos de recente decisão, cuja fundamentação reitero.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Providencie-se, também, após o trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condeno os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º,

da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eldorado, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA